

1500897-02.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... para intimidação difusa ou coletiva na prática do tráfico.

A propósito:

"Apelação da Defesa - Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - Concurso material - (...) - O reconhecimento do concurso material de crimes afasta, por lógica, a pretensão da defesa de aplicação do princípio da consunção entre os delitos - Preliminar rejeitada - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500897-02.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500897-02.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2281025/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 20830570 - 2º Distrito Policial de Lorena, 44/21/213 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2281025 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 44/21/213 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DOS SANTOS JESUS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de EDUARDO DOS SANTOS JESUS, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03, em concurso material; conforme os fatos narrados na peça inicial de fls. 71/72.

Recebida a denúncia em 19/10/2021 (fls. 89/93), o réu foi citado. Defesa prévia apresentada às fls. 103/105. Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 112/113).

No curso da instrução foram ouvidas testemunhas, sendo o réu interrogado, ao final. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais, por meio de memoriais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 164/167).

A defesa, por sua vez, requereu sua absolvição. Preliminarmente, sustentou a nulidade das provas, alegando que as provas foram produzidas com violação ao direito de domicílio. No mérito, requereu a absolvição do acusado por ter agido sob coação moral irresistível; e a absorção do crime de armas, pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da figura privilegiada do tipo; a fixação do regime inicial diverso do fechado; e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 169/174).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifico que a serventia não cumpriu integralmente a decisão de fls. 89/93, quanto ao decreto de quebra do sigilo bancário e telefônico do réu.

Porém, em se tratando de feito em que o acusado encontra-se recolhido provisoriamente, e que as partes não se manifestaram a esse respeito na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, passo desde já a sentenciá-lo.

Providencie a serventia o cumprimento integral dessa decisão e com a vinda desses elementos de prova, abra-se vista ao Ministério Público, para que, se entender pertinente, nos termos do artigo 40, do Código de Processo Penal, ofereça denúncia ou requirite a instauração de inquérito policial, nos termos do artigo 5º, inciso II, do mesmo Código, em novos autos.

Com relação à preliminar invocada, malgrado o respeito destinado ao nobre defensor, não é o caso de acolhê-la.

O Juízo não desconhece o entendimento que vem se formando no Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévia autorização do morador da residência para incursão policial, em respeito ao direito à inviolabilidade domiciliar.

Porém, tenho que a ação policial em questão observou os limites da Constituição Federal. Diferentemente do que ocorre em outras situações, verifico que a entrada dos policiais civis no imóvel foi precedida de investigações e motivada pelo próprio comportamento do réu, surpreendido transportando para o interior do imóvel grande quantidade de entorpecentes, conforme se verá mais à frente.

Logo, em virtude do estado flagrancial, expressamente excepcionado pela própria norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), mostrou-se perfeitamente legítimo o agir dos agentes públicos.

Saliente-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, debruçando-se sobre o tema em sede de repercussão geral (Tema 280), estabeleceu as diretrizes para o controle judicial nessas hipóteses, firmando a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Portanto, não se pode dizer que a conduta dos agentes públicos não estava amparada por fundadas razões (justa causa), à luz das investigações pretéritas e da própria postura do réu, ainda mais quando se tem informações, oriundas de interceptações telefônicas devidamente autorizadas judicialmente, do seu envolvimento em delito permanente, tal como mencionado pelos agentes estatais.

A propósito, em caso muito semelhante ao destes autos:

"Apelação - Tráfico - Condenação da corré CREUSA e absolvição da corré JENIFFER - Recurso do Ministério Público que busca a majoração da pena e a fixação de regime fechado para a condenada CREUSA, bem como a condenação da corré JENIFFER, nos termos da denúncia - Recurso da corré CREUSA que alega preliminar de nulidade e busca a absolvição - Preliminar de nulidade da prova por invasão de domicílio sem mandado judicial - Inocorrência - Possibilidade de ingresso no domicílio quando ocorrente situação de flagrante delito - Preliminar afastada - Conduta da corré CREUSA de trazer consigo e ter em depósito, 426 gramas de maconha - Diligência policial que teve lastro em interceptação telefônica (...) - Recursos do Ministério Público e da defesa da corré CREUSA desprovidos, mantida, na íntegra, a bem lançada sentença". (TJSP; Apelação Criminal 0001776-83.2017.8.26.0537; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 22/10/2019) (Sublinhado meu).

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, especialmente o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 16/18); auto de exibição e apreensão (fls. 19/20); fotografias (fls. 26 e 28/44); laudo químico toxicológico definitivo (fls. 80/82), com resultados positivos para "cocaína" e tetrahydrocannabinol - THC - "maconha", substâncias presentes nas listas da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; laudo pericial da arma de fogo e das munições (fls. 120/123), cujo resultado atestou o potencial lesivo das munições e a eficácia do armamento; posteriormente renovados sob o crivo do contraditório pelas provas orais.

A prova de autoria restou igualmente comprovada. A começar pela confissão do acusado.

Decerto, durante o ato destinado à sua autodefesa, o réu admitiu o narcotráfico. Procurou justificar o ato, dizendo que estava sendo coagido por traficantes que ceifaram a vida de sua esposa.

No entanto, esclareço que a prova acusatória não se resume à confissão de Eduardo.

Com efeito, o policial civil Jeferson Luiz Gonçalves contou que havia uma investigação em curso na delegacia especializada no combate ao tráfico de drogas (DISE), tendo como alvo uma associação criminosa atuante nas cidades de Aparecida/SP, Guaratinguetá/SP e Lorena/SP. Disse que os traficantes tinham o costume de aliciar pessoas para guardar e transportar entorpecentes negociados pela quadrilha. Relatou que as investigações apontaram uma residência na qual havia um carro modelo siena, de cor branca, no bairro "Cecap", sendo que, em diligências no local um dia antes dos fatos, ora julgados, avistaram o veículo da esposa de Maurício Mendes, pessoa apontada como chefe do bando. De acordo com o depoente, a esposa de Maurício chegou a ser abordada naquela ocasião, nada de ilícito sendo localizado em sua posse, ou mesmo em seu veículo. Disse que, após tal evento, naquela investigação, com autorização judicial, interceptou-se uma ligação telefônica na qual Maurício dava ordens para o réu retirar os ilícitos de sua residência. Diante de tal informação, no dia dos fatos, a polícia civil realizou

campana na tentativa de verificar a veracidade da ligação, obtendo êxito em surpreender o acusado saindo da residência no bairro "Cecap", em comportamento suspeito (olhava para todos os lados, dando várias voltas no mesmo quarteirão), até parar em uma casa no bairro "Santo Antônio". Abordado, encontrou-se em seu poder grande quantidade de entorpecentes (25 tabletes de "maconha"), no veículo siena branco. Afirmou que o réu, inicialmente, negou os fatos, porém, após a apreensão dos entorpecentes no veículo, confessou informalmente que havia mais drogas no interior daquele imóvel, cerca de 40 "tijolos de maconha", e que, de fato, as guardava, sob a promessa de recebimento da quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), esquivando-se de apontar o proprietário dos narcóticos, todavia. Segundo a testemunha, no interior da casa foram apreendidos "maconha", "cocaína", arma de fogo e munições.

O investigador de polícia Rafael Carvalho de Paula fez coro às suas declarações. Tal testemunha ainda revelou que, após a prisão do acusado, em outra ligação telefônica interceptada entre Maurício e sua esposa, aquele lhe contou sobre as perdas financeiras decorrentes dos fatos, ora julgados, ordenando-lhe que Ester se livrasse do seu veículo. Questionado, disse que o alvo principal das investigações era Maurício que, apesar de preso há tempos, continuava praticando delitos, em concurso com sua esposa Ester, em liberdade à época. O depoente esclareceu que desconhecia o acusado, embora conhecesse sua esposa, assassinada por disparos de arma de fogo.

Já as testemunhas de defesa ouvidas (Luciano dos Santos e Tássia Fernanda Gomes Leite) limitaram-se a atestar a boa conduta social do acusado.

Por sua vez, o réu confessou os crimes em seu interrogatório. Contou que sua mulher possuía uma dívida com traficantes, sendo morta por tal motivo. A partir desse fato, contou que os credores de sua falecida esposa exigiram que ele guardasse as drogas apreendidas para quitar sua dívida. Afirmou que somente soube do envolvimento da sua esposa com o vil comércio depois de sua falecimento. Afirmou que as drogas ficariam em sua posse por apenas três dias. Questionado, disse que apenas os seus filhos, menores de idade, sabiam das ameaças dos traficantes. Relatou que morava em um dos "Predinhos da Cecap", e de lá se mudou por causa do assassinato de sua esposa, e que estava trabalhando como ajudante de pedreiro, recebendo R\$ 400,00 (quatrocentos reais) por semana. Disse que a arma de fogo apreendida lhe foi entregue junto com a droga para protegê-la, enquanto o valor encontrado em seu poder (R\$ 500,00), destinava-se a gasolina no veículo. Por fim, declarou que as ordens dos traficantes vinham por bilhetes em sua caixa de correio, e que não procurou a polícia pelo receio de morrer.

Eis, portanto, as provas dos autos.

Pois bem. Como se vê, a prova em juízo não destoou em momento algum da confissão do réu, encontrando amplo amparo no conjunto probatório, em especial, nos depoimentos dos policiais responsáveis por realizarem sua prisão em flagrante.

De fato, a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado aos autos, frise-se, desde a fase pré-processual; fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação.

Se, por outros elementos de convicção, a palavra do réu soasse inverídica ou estivesse isolada nos autos, o desfecho condenatório poderia ser contestado, o que não aconteceu no presente caso, posto que a admissão de culpa externada pelo acusado foi corroborada, também, pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pelas diligências policiais e pela prisão em flagrante, confirmando a versão acusatória da exordial.

Anote-se que as testemunhas arroladas pela defesa nada disseram nada sobre os

fatos, apenas sobre a vida pregressa do increpado.

Como se vê, não há nada nos autos a infirmar ou mesmo levantar suspeitas sobre os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação ouvidas. No caso em foco, estão absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos e em total sintonia com os demais elementos carreados para os autos.

A propósito, em recente julgado:

“Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – (...) Consistentes relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão judicial do réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Condenação mantida – (...) – Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final”. (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Lado outro, refuta-se a tese de coação moral irresistível.

À luz dos artigos 22 e 24, do Código Penal, por qualquer ângulo que se analise, inviável reconhecer qualquer das excludentes na hipótese dos autos (prática de tráfico de entorpecentes para adimplir dívidas pretéritas).

É requisito das excludentes, sejam de culpabilidade ou de ilicitude, a involuntariedade e estado atual, o que não ocorre neste caso, já que a alegada pendência financeira fora contraída por livre e espontânea vontade pela mulher do acusado.

Ademais, inexistente sequer início de prova a confirmar a situação invocada, esclarecendo-se que a mera menção pelo réu não é suficiente para o seu reconhecimento, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, o mesmo entendimento recente do nosso Tribunal:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Apelo da defesa – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento de excludente de ilicitude (estado de necessidade) ou excludentes de culpabilidade (coação moral irresistível e inexigibilidade de conduta diversa) – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500194-49.2019.8.26.0263; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itai - Vara Única; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022);

“TRÁFICO DE DROGAS – (...) – AUTORIA – confissão do réu em sintonia com a prova coligida - depoimento de policiais que confirmam a apreensão de drogas em poder do réu e na residência dele – validade – (...). COAÇÃO IRRESISTIVEL - inviabilidade do reconhecimento da excludente de culpabilidade - alegação de que estava comercializando drogas porque precisava pagar dívida por entorpecentes apreendidos anteriormente e que estava sendo ameaçado para tanto - não comprovação nos autos - ônus que incumbia à Defesa – inteligência do art. 156 do CPP - improvimento ao apelo. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1503571-52.2020.8.26.0664; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Registro: 11/03/2022) e

“Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa apela a absolvição com base em excludente

de culpabilidade (coação moral irresistível) e, subsidiariamente, o reconhecimento das causas de diminuição de pena constantes ao artigo 33, parágrafo 4º e 4º e ao artigo 41, ambos da Lei 11.343/06. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais. Coação moral irresistível não comprovada. Simples menção à ameaça e ao primeiro nome do suposto mandante insuficientes para afastar a condenação. (...) Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501474-29.2021.8.26.0540; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021) (Sublinhados meus).

Por fim, esclareço ser desnecessário para configuração do crime de tráfico de drogas que o agente seja flagrado em atos efetivos de mercancia, uma vez presentes duas das múltiplas ações previstas no tipo penal, no caso, o transporte e a guarda, sendo certo que a finalidade mercantil deve ser demonstrada pelas circunstâncias do caso, tal como a hipótese dos autos, como a exorbitante quantidade e diversidade de entorpecentes (aproximadamente 68 Kg de "maconha" e "cocaína"), e a apreensão de balança de precisão.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Lado outro, com relação ao crime da lei de armas, conforme a prova oral, corroborado pela confissão do acusado, é fato que este possuía arma de fogo e munições.

Como se sabe a exigência legal de regularização desses armamentos não é mera burocracia estatal, é garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam arma de fogo.

Ressalto, também, que o crime de posse ilegal de arma de fogo e munições é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Logo, para o reconhecimento da autoria de tal delito, basta a vontade livre e consciente de possuir arma de fogo sem a devida autorização legal, o que ficou evidente no presente caso, diante da confissão do acusado e do depoimento das testemunhas de acusação.

Não é demais destacar que o laudo pericial acostado aos autos (fls. 120/123) atestou que as munições foram percutidas, detonadas e deflagradas, mostrando-se a

arma de fogo apta a realizar disparos, tal como revelado nos testes, comprovando-se eficazmente o potencial lesivo das mesmas.

Por fim, inviável o acolhimento da tese de absorção do crime de posse de arma de fogo e munições, à míngua de provas a indicar que o armamento apreendido no interior de sua residência seria utilizado para intimidação difusa ou coletiva na prática do tráfico.

A propósito:

"Apelação da Defesa - Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida - Concurso material - (...) - O reconhecimento do concurso material de crimes afasta, por lógica, a pretensão da defesa de aplicação do princípio da consunção entre os delitos - Preliminar rejeitada - Mérito - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de porções de maconha, de 'crack' e de cocaína em poder dos acusados - Apreensão de um revólver na residência de Samuel - (...) Condutas praticadas em contextos distintos, a tornar inaplicável a causa de aumento da pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, em detrimento do concurso material de infrações - Rejeitada a preliminar, recurso desprovido. (...)". (TJSP; Apelação Criminal 1500259-86.2018.8.26.0228; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020) (Sublinhados meus).

Portanto, de rigor a condenação do réu, nos exatos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

a) Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

O acusado é primário e de bons antecedentes (fls. 131/132).

Todavia, merece consideração negativa nesta etapa, a reprovabilidade excessiva da conduta censurada, à luz da absurda quantidade e diversidade de entorpecentes. Afinal, tendo em conta que o tipo penal em questão visa tutelar o bem jurídico saúde pública, tão caro à sociedade, deixar de valorar de modo depreciativo quem é surpreendido com 59,27 Kg, de massa líquida, de "maconha"; 7,80 Kg, massa líquida, de "cocaína", significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas nas quais envolvem apreensão de pequena quantidade.

Portanto, diante dessas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 2/3 (dois terços) acima do piso legal, ou seja, 08 anos e 04 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na etapa intermediária, reconheço em favor do réu, a atenuante da confissão espontânea. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, por inexistirem outras circunstâncias modificadoras.

Não é o caso de reconhecer a figura privilegiada do tipo, na medida em que as circunstâncias do caso concreto revelam a profunda intimidade do acusado com o narcotráfico, apesar de sua condição de primário aos olhos da lei penal.

A uma, porque as testemunhas de acusação relataram que o acusado integrava uma complexa organização criminoso voltada ao tráfico de drogas atuante nesta região, sendo responsável pela guarda e transporte dos entorpecentes.

A duas, posto que apreendido juntamente com as drogas, apetrecho utilizado no vil comércio para venda no varejo (balança de precisão), a demonstrar que o réu também atuava na manipulação daqueles entorpecentes.

A três, pela própria desmesurada quantidade e diversidade das drogas, certamente inacessível a um noviço na vil empreitada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Aliás, como não existe prova direta dessa circunstância, dedicar-se à atividade criminosa, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'”, é exatamente essas circunstâncias que comprovam a sua dedicação, conforme julgado que assim se encontra a ementa:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se

dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Outro não é o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

"Tráfico de entorpecentes. (...) Insurgência defensiva em face da pena. Reprimendas irreprocháveis. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não fazem jus às acusadas. Dedicção à atividade criminosa. Volume considerável de droga que revela não serem as rés meras aventureiras no ramo da narcotraficância (...) Precedentes do STJ. Negado provimento ao apelo". (TJSP; Apelação Criminal 0002163-92.2017.8.26.0539; Relator: Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 01/02/2020) (Originais sem marcações).

Assim, como determina a lei, tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, hipótese destes autos, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida do acusado.

Registro, por fim, que tal entendimento encontra-se em linha, ainda, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, já que a quantidade de droga apreendida não foi o único elemento a ensejar a não aplicação do § 4º, do artigo em assunto, como se vê acima nos elementos do caso, não podendo cogitar o proibido bis in idem.

A propósito, em recente julgado:

"PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade

das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença". (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (Sublinhado meu).

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal, por serem tais medidas incompatíveis com a natureza hedionda do crime, ora em voga. Ainda que assim não fosse, o montante de pena aplicado, por si só, as inviabilizaria.

b) Crime do artigo 12, da Lei 10.826/03:

Como exposto anteriormente, o réu não possui maus antecedentes.

No entanto, cabe apontar a maior reprovabilidade da conduta, na medida em que a arma de fogo estava acompanhada de diversas munições, de modo a incrementar o risco ao bem jurídico.

Portanto, estabeleço a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do piso, ou seja, em 01 ano e 02 meses de detenção e 11 dias-multa.

Por ser confesso, reduzo em 1/6 (um sexto) a sanção, reconduzindo-a ao patamar mínimo de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em respeito à Súmula 231 do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Não havendo mais causas modificadoras, torno-a definitiva.

O regime inicial será o semiaberto, à luz das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como diante do concurso de crimes, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação de medidas despenalizadoras.

Em se tratando de concurso material de delitos, na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas deverão ser somadas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, para ambos os delitos, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, com base no artigo 43, da Lei 11.343/06, e artigo 60, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar EDUARDO DOS SANTOS JESUS, por violação aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12, da Lei 10.826/03, às penas de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, diária mínima; e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e multa de 10 (dez) dias-multa, diária mínima; respectivamente, na forma do artigo 69 do CP.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do réu se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Ademais, não faz qualquer sentido soltar o réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, agora, depois de condenado.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também garantir a ordem pública, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

No entanto, havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

Caso ainda não se tenha feito, em cumprimento às decisões anteriores, encaminhem-se as drogas apreendidas, bem como os demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição.

Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, nada a apreciar com relação a elas. Já com relação à arma de fogo, apreendida na mesma oportunidade, determino a remessa ao Exército para as finalidades cabíveis, nos termos do que dispõe o artigo 25, da Lei 10.826/03.

Decreto o perdimento do veículo (Fiat/siena, placas CXP8526) apreendido às fls. 19/20 em favor da União, ante as evidências da sua utilização no transporte das

drogas, à luz da prova oral colhida, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Importante mencionar sobre o assunto, que o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu em recurso extraordinário, com repercussão geral, o Tema 647, que o perdimento do bem, como no caso destes autos, do veículo, não é necessária a habitualidade na atividade ilícita, ou que o carro tenha sido de alguma forma modificado para o transporte dos narcóticos, logo, como restou cabalmente comprovado que o réu se utilizou desse automóvel para transportar a droga, frise-se: ainda que, somente nesta ocasião; é o caso do seu perdimento.

Veja-se o posicionamento daquele Supremo Tribunal, bem como do E. Tribunal de Justiça deste estado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (STF; RE 638491; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. Luiz Fux; Julgamento: 17/05/2017; Publicação: 23/08/2017); e

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelos defensivos – Inconformismo que se limita ao capítulo da sentença que decretou o perdimento do automóvel e dos telefones celulares apreendidos – Pretensão de cassação desse decreto sob os argumentos de que ele não se aplica ao tráfico privilegiado, os bens têm origem lícita e não há habitualidade no uso deles para a prática de tráfico de drogas – Caso em que esse uso está bem demonstrado – Exigência de habitualidade que é questão controversa no STJ, de modo que não há razão para abandono do entendimento adotado pela Câmara em sede de embargos infringentes: “O fato do carro, eventualmente, possuir origem lícita ou estar registrado em nome de terceiro estranho ao delito, por si só, não obsta a decretação de seu perdimento – Precedentes do STF” – (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1506190-65.2021.8.26.0228; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) (Sublinhados meus).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA